

1501171-90.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... local para investigar ocorrências de tráfico de drogas. Pelo contrário, restou bem demonstrado durante a instrução que tal tese é falsa.

Malgrado as testemunhas tenham narrado o conhecimento prévio de que, na região em que se deram os fatos, ocorria a atividade ilícita do tráfico de drogas e que a ronda por eles realizada destinava-se, também, a coibir eventuais práticas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501171-90.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501171-90.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON ARAÚJO DA CONCEIÇÃO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

EDSON ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", deste mesmo diploma legal, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, em ocasião de calamidade pública, auxiliou, exercendo a função conhecida como "água", indivíduos não identificados a trazerem consigo drogas, para fins de tráfico, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia que, com o acusado, foi apreendida a quantia de R\$9,00, tendo sido apreendida, próxima a ele, uma mochila contendo 69 porções de maconha, 144 pedras de crack, 120 porções de cocaína, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, bem como um caderno com anotações que indicavam contabilidade da atividade de tráfico de drogas, além de uma arma de fogo conhecida como garrucha.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas na denúncia, sendo homologada a desistência manifestada pelas partes quanto à oitiva de uma testemunha policial civil. Ao final, foi o réu interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação para condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou pedidos relativos à fixação da pena e do regime prisional.

A Defesa, por sua vez, suscitou preliminarmente a nulidade da prisão do réu, que teria decorrido de atos investigatórios realizados por guardas municipais. No mérito, pugnou pela absolvição do réu, por falta de provas quanto à realização do tráfico de drogas. Requereu, outrossim, a desclassificação do crime para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou para a conduta tipificada no artigo 37 da referida lei. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal, com aplicação da causa especial de diminuição de pena, além da fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

A preliminar arguida pela Defesa quanto à ilegalidade da prisão do acusado, efetuada por guardas municipais, não merece guarida.

Ao contrário do alegado pela combativa Defesa, nada há nos autos a indicar que os guardas municipais estivessem no local para investigar ocorrências de tráfico de drogas. Pelo contrário, restou bem demonstrado durante a instrução que tal tese é falsa.

Malgrado as testemunhas tenham narrado o conhecimento prévio de que, na região em que se deram os fatos, ocorria a atividade ilícita do tráfico de drogas e que a ronda por eles realizada destinava-se, também, a coibir eventuais práticas ilícitas, verifica-se que o patrulhamento por eles realizado tratava-se de atividade de rotina na região em que há área de proteção ambiental, além de equipamentos públicos como escolas e creches.

Inferre-se de seus depoimentos que, ao passarem pelo local dos fatos, visualizaram indivíduos que estavam em área de mata, já conhecida pela ocorrência do tráfico de drogas, e viram que estes empreenderam fuga. Diante da fundada suspeita, realizaram a abordagem do acusado e apreenderam, ao seu lado, grande quantidade de drogas.

Veja-se que os integrantes da guarda municipal, embora tenham como função precípua a proteção do patrimônio municipal, não estão impedidos, tal como qualquer pessoa do povo, de realizar a prisão em flagrante, fazendo cessar prática criminosa que seja por eles presenciada, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, conduta esta que não se confunde com usurpação de funções das polícias militar ou civil.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa (AgRg no HC n. 667.413/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes. No caso vertente, houve a fundada suspeita para a atuação da Guarda Municipal. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada.

2. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese

de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório pelo delito de tráfico. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de prova para a condenação, ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte agravante, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp n. 2.037.067/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/4/2022.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ILICITUDE DAS PROVAS. ATUAÇÃO INVESTIGATIVA DA GUARDA MUNICIPAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa" (AgRg no HC 667.413/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 16/6/2021).

2. Na espécie, os guardas municipais, em patrulhamento de rotina, avistaram o exato momento em que o agravante realizava a venda de entorpecentes, razão pela qual o prenderam em flagrante.

3. O pleito de desclassificação da conduta de tráfico para a de uso de entorpecente demandaria inevitável revolvimento de matéria fático-probatória, o que se não mostra viável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

4. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

5. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

6. No caso em tela, não foi reconhecida a incidência da minorante com base na dedicação do paciente à atividade criminosa, tendo em vista a anterior prática de atos infracionais, com observância aos pormenores da situação concreta e respeitando os critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo excluída a possibilidade de aplicação do pretendido redutor.

7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 703.036/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/3/2022.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil CPC c/c o 3º do Código de Processo Penal CPP, e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ, além do enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte tem admitido a realização de busca pessoal e a prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante nos artigos 240, § 2º, 244 e 301 do Código de Processo Penal.

In casu, o agravante foi surpreendido por guardas municipais quando trazia uma sacola contendo entorpecentes. Ao notar a aproximação, o denunciado tentou empreender fuga, adentrando em vegetação próxima a uma área desabitada, porém terminou detido. Na referida sacola plástica foram encontradas as drogas: - 33 porções de maconha (148, 44g), 103 de cocaína (133,85g) e 30 pedras de crack. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 679.338/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para se acolher a pretendida absolvição da Agravante, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus, pois o Tribunal de origem entendeu que existem provas suficientes para a sua condenação.

2. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexistente ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais.

3. Havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa.

4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 695.254/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/11/2021.)

Assim, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante do acusado.

No mérito, a materialidade do crime ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelos laudos periciais, bem como pelo conjunto probatório constante dos autos.

Também não restam dúvidas quanto à autoria.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do delito descrito na denúncia.

Contou que sua residência é próxima ao local dos fatos e estava caminhando na direção do ponto de tráfico, para adquirir crack de indivíduos que estavam no fundo da mata, e disse que outros três indivíduos, também usuários, seguiam pelo mesmo caminho. Alegou que cerca de quatro a cinco policiais chegaram ao local, passaram por onde estava caminhando, foram ao fundo do mato e depois retornaram com uma mochila, abordando-o. Contou que os outros indivíduos que estavam indo em direção ao ponto de tráfico foram dispensados, tendo sido o único a permanecer detido.

Disse que costuma frequentar aquele local para comprar drogas, pois é a única "biqueira" próxima à sua casa.

Entretanto, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se a realização do auxílio ao tráfico de drogas. Além disso, a versão apresentada pelo acusado em Juízo não é crível em face do restante das provas produzidas durante o processo.

A testemunha guarda civil municipal Marco Antonio Cecato, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que realizava patrulhamento em local onde já havia registros da ocorrência de tráfico de drogas anteriormente e, percebendo a presença de pessoas no interior da mata, desembarcou da viatura e viu que três indivíduos que estavam mais acima no morro empreenderam fuga pela mata. Narrou que o réu estava sentado e, possivelmente, não viu a aproximação da equipe, sendo então abordado. Declarou que, ao lado do acusado, havia uma mochila, onde foram encontradas drogas, em quantidade que não recordou, mas consignou serem porções de maconha, crack e cocaína, além de uma garrucha, e também desodorante, capa de chuva e carregador de aparelho celular. Relatou que, com o réu, foi encontrado somente quantia em dinheiro, em torno de cinco a dez reais. Consignou que a mochila apreendida estava próxima ao acusado, ao alcance de seu braço. Disse que, questionado sobre os fatos, o réu alegou ser apenas usuário de drogas, negando a propriedade do material apreendido, e não fez menção às pessoas que haviam se evadido. Declarou que não conhecia o réu anteriormente aos fatos. Consignou que havia visualizado apenas quatro indivíduos, sendo um deles o acusado e os outros três aqueles que estavam mais acima do morro e fugiram. Declarou que o acusado não chegou a fugir, pois a

abordagem ocorreu rapidamente. Disse que, ao realizar o patrulhamento pela região em que ocorreram os fatos, este também é realizado com vistas a coibir o tráfico de drogas em local já conhecido por esta prática. Relatou que a região de mata trata-se de área de proteção ambiental, havendo também escolas e creches próximas. Esclareceu que não recebeu ordem específica para o combate ao tráfico de drogas, consignando que a ação ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando deparou-se com os quatro indivíduos no local.

A testemunha guarda civil municipal Leandro José de Souza, ouvida em Juízo, narrou que realizava patrulhamento por local conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas quando avistou o acusado com outros três indivíduos, sendo que, ao ver a viatura, eles saíram correndo, mas o réu foi abordado. Relatou que, próximo ao acusado, foi encontrada uma mochila contendo drogas e uma arma antiga. Disse que, questionado, o réu alegou que estava no local para fazer uso de entorpecentes, negando a participação no tráfico de drogas, dizendo, também, que possuía problema psicológico e que nada havia com ele, sem admitir a propriedade da droga encontrada. Consignou que os outros três indivíduos estavam próximos ao acusado antes de empreenderem fuga. Disse que a mochila apreendida estava a cerca de dois metros do acusado e não estava a seu alcance, mas esclareceu que não recordava com exatidão desta circunstância. Declarou que já havia visto o acusado anteriormente naquela localidade, mas somente o abordou na data dos fatos descritos na denúncia. Relatou que o acusado e os demais indivíduos estavam na entrada da mata, que fica em uma rua, sendo que o réu tentou empreender fuga, mas não conseguiu, pois estava com a perna machucada. Esclareceu que estava conduzindo a viatura e seu parceiro de ofício foi o primeiro a desembarcar, sendo que seu parceiro de farda já havia abordado o acusado quando dele se aproximou. Disse que o irmão do réu compareceu à delegacia, informando que ele era usuário de drogas e residia naquele mesmo bairro onde ocorreram os fatos. Relatou que o patrulhamento no local é realizado, também, com vistas ao combate ao tráfico de drogas, mas consignou que o patrulhamento realizado ocorreu em atividade de rotina e genérico, sendo que, ao ver indivíduos correndo ao ver a viatura, houve a ação da guarda.

A testemunha policial civil Jorge Ricardo Cardoso Villar relatou que não participou de qualquer diligência policial relativa aos fatos descritos na denúncia. Declarou que, no ano de 2019, participou, em apoio a outros policiais, de ação policial em que ocorreu troca de disparos em meio a local de mata. Disse que não presenciou a troca de tiros, assim como o policial Adilson que estava consigo não a presenciou. Narrou que, naquela data, enquanto o policial Adilson desembarcou da viatura em apoio aos demais policiais na mata, permaneceu no veículo e abordou o acusado Edson, que estava correndo de dentro da mata. Disse que, de acordo com informações dadas pelos policiais que estavam realizando a incursão na mata, Edson seria o “olheiro” ou “água” do local, que alertava sobre a presença da polícia. Narrou que, naquela data, Edson admitiu, informalmente, exercer a função de “água”.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminoso do acusado, no que se refere à colaboração, como informante, com grupo destinado ao tráfico de drogas, diante dos relatos apresentados pelas testemunhas guardas municipais.

No presente caso, a palavra dos agentes de segurança, que de maneira uniforme e convincente, descreveram com detalhes como ocorreu a abordagem do acusado e a apreensão das drogas que estavam próximas a ele, não restou abalada.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos dos agentes de segurança.

Como já se decidiu “é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse

convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal). Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2. T.- HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.

2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC

156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).
Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10).
3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842).
4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção de ofício.
5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP - Rel. Min. Luiz Fux - j. 25.02.14 - DJU 18.03.14; HC 118.380/SP - Rel. Min. Teori Zavaski - j. 04.02.14 - DJU 14.02.14; HC 116.541/ES - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 21.05.2013 - DJE 06.06.13; HC 109.236/SP - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 13.12.11 - DJU 14.23.12). Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.
6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.
7. Provimento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

"Tráfico de entorpecentes - Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes - Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor - Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que

assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena - Tráfico de Entorpecentes - Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido - Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena - Tráfico de entorpecentes - Desnecessidade de comprovação de nexos causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino - Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva - Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva." (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

Apenas para consignar, o esforço da Defesa em desqualificar os depoimentos das testemunhas guardas municipais que realizaram a abordagem do acusado e a apreensão das drogas não é suficiente para retirar a força probante deles.

Veja-se que ambas as testemunhas guardas civis municipais asseveraram que viram indivíduos empreendendo fuga em local já conhecido por eles pela ocorrência do tráfico de drogas e, então, realizaram a abordagem do acusado, localizando, próxima a ele, a mochila que continha as drogas variadas, bem como uma arma de fogo.

Consignou a testemunha Leandro que seu parceiro de farda Marco Antonio foi o primeiro a desembarcar da viatura e foi ele quem primeiro chegou ao local onde estava o acusado e realizou sua abordagem.

A testemunha Marco Antonio afirmou que viu os outros três indivíduos mais acima do morro e estes empreenderam fuga ao notar a aproximação da viatura, porém o acusado, que estava sentado, foi abordado. Consignou que, ao lado do acusado, ao alcance dele, foi localizada e apreendida a mochila contendo os entorpecentes e o armamento.

Dessa forma, não há dúvidas de que o acusado foi detido em local já conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas e que, ao lado dele, foi encontrada grande quantidade de entorpecentes variados.

Outrossim, há nos autos elementos que demonstram o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas ali realizado.

Veja-se que a testemunha policial civil Jorge Ricardo, embora não tenha participado de nenhuma diligência referente aos fatos descritos na denúncia, afirmou que, no ano de 2019, quando compunha equipe de apoio a outros policiais que faziam incursão na mesma área de mata em que se deram os fatos, realizou a abordagem do acusado.

Consignou que, naquela ação policial, houve troca de disparos de arma de fogo na mata e os policiais envolvidos naquela diligência apuraram que o réu exercia a função de "olheiro", narrando que o próprio acusado, informalmente, havia admitido, naquele momento, realizar a atividade de "olheiro" para a prática do tráfico de

drogas.

Em adição às declarações da testemunha Jorge, observe-se que a testemunha Leandro afirmou que já havia visto o acusado naquela mesma área anteriormente, embora somente o tenha abordado na data dos fatos.

De outro lado, em que pese haver demonstração do envolvimento do acusado na atividade do tráfico de drogas, não há elementos suficientes que demonstrem que o réu exercia sua atividade de forma estável, nem mesmo que possuía vínculo efetivo com o grupo criminoso que ali realizava a mercancia ilícita.

Veja-se que, embora tenha sido indiciado em inquérito policial em que apurava o tráfico de drogas ocorrido no ano de 2019 (autos de nº 1502663-25.2019.8.26.0536), não foi o acusado denunciado naqueles autos, nem mesmo respondeu a nenhum outro processo em que fosse investigado o delito de tráfico de drogas.

Outrossim, apesar de ter a testemunha Leandro consignado já ter visto o acusado na região em que ocorreram os fatos em outros momentos, não foi destacada por ela nenhuma outra informação sobre a efetiva atividade ilícita praticada de forma contínua pelo acusado.

Portanto, é caso de desclassificação de sua conduta para aquela prevista no artigo 37 da Lei nº 11.343/06.

Confira-se, nesse diapasão, o entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO. OLHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO. INCIDÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ARTIGO 37 DA LEI N. 11.343/2006. PRECEDENTES.

1. A conduta de olheiro tanto pode se enquadrar no delito tipificado no artigo 37 como nos artigos 33 ou 35 da Lei n. 11.343/2006, a depender da comprovação da estabilidade ou não do vínculo. 2. Assim, se restar comprovado nos autos que o indivíduo colabora com o grupo prestando informações de forma esporádica, eventual, sem vínculo efetivo, a conduta se encaixará na norma descrita no artigo 37 da referida lei. Ao contrário, se ficar demonstrado que a função é exercida de forma estável, constituindo-se o modo pelo qual o agente adere aos fins do grupo criminoso, a hipótese será enquadrada no crime do artigo 35, ou mesmo, 33 da Lei Antidrogas, a depender das circunstâncias.

4. É incontroverso nos autos que o réu portava um rádio comunicador, com a finalidade de avisar aos traficantes da localidade acerca da chegada da polícia no local, porém, em nenhum momento há o reconhecimento da estabilidade de seu envolvimento com o tráfico de drogas, ou seja, não ficou demonstrado um vínculo efetivo com o grupo criminoso, apenas foi narrada uma única conduta desvinculada de qualquer outra finalidade, devendo, portanto, a hipótese ser enquadrada no artigo 37 da Lei Antidrogas.

5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1.738.851/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 30/8/2018.)

Por consequência lógica, incabível a tese de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Diante do cotejo probatório trazido aos autos, a condenação do réu quanto ao crime tipificado no artigo 37 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

Parcialmente procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

O réu não possui maus antecedentes e, diante da desclassificação de sua conduta, não há razões para a fixar-se sua pena-base acima do mínimo legal. Assim, fica sua pena-base fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro

adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal em 1/6, a qual resta fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

À míngua de outras causas modificadoras da pena, torno essa pena definitiva.

Verifica-se, portanto, fixação de pena em patamar inferior a quatro anos o que, atualmente, preenchidos os demais requisitos legais, enseja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A expressa vedação quanto à substituição de pena constante do artigo 44 da lei 11.343/06 foi suspensa pela Resolução nº 5/2012 do Senado Federal.

Em caso de descumprimento o regime inicial de pena privativa de liberdade será o regime aberto.

Passo, portanto, a análise dos requisitos legais. Estando presentes os requisitos previstos nos incisos I (crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais favoráveis) do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade, que deverá ser cumprida a razão de uma hora para cada dia de condenação, em local a ser fixado pelo juiz da execução, e também pela pena de outros 10 (dez) dias-multa, no mesmo valor já estipulado.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu EDSON ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso no artigo 37 da Lei nº 11.343/06, ficando a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e multa no valor equivalente a 10 dias-multa, como acima especificado.

Diante do montante de pena privativa de liberdade imposta e a substituição aplicada, não mais se justifica a manutenção da prisão cautelar do acusado, motivo pelo qual lhe concedo o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado.

Decreto o perdimento do valor apreendido nos autos em favor da União, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA